

1500902-56.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o tema, o seguinte julgado: "Habeas Corpus - Tráfico de drogas- Pleito de revogação da prisão preventiva - Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade - Artigo 301 do CPP - Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante - Crime de Tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500902-56.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000741

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166565/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25650917 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2166565 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS MICAEL GREGORIO e outro

Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. ANTONIO CARLOS PEREZ ANTUNES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: ELIAS MICAEL GREGORIO - AUSENTE

Réu: DANIEL SILVESTRE PIRES - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC DOMICIANO MARQUES COIMBRA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, ante à ausência do réu, pela MM. Juíza foi dito: "DECRETO A REVELIA DO RÉU, que não compareceu à presente audiência mesmo tendo sido intimado, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 188". A seguir, foi colhido o depoimento da testemunha GC DOMICIANO MARQUES COIMBRA.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.
Após, o réu DANIEL SILVESTRE PIRES foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "DANIEL SILVESTRE PIRES e ELIAS MICAEL GREGÓRIO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 20 de março de 2022, por volta de 21h50min, na Rua Dona Rosália, nº 330, bairro Paulicéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, agindo em concurso, caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios, e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si 4,4kg de fios e cabos, instalados em torre de telefonia e pertencentes à empresa Vivo – Telefônica Brasil S.A, somente não consumando a infração por circunstâncias alheias a suas vontades (fls. 57/59) O processo teve trâmite regular, sendo os réus citados, ouvida as testemunhas e, após, interrogados. É este o relato do necessário. A ação penal é procedente. A materialidade restou confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fls. 15, fotografias de fls. 16/17 e laudos periciais a fls. 179/184 e 185/186. Da mesma forma, a autoria delitiva. De fato, na fase informativa, o guarda (fls. 03), disse que "estava com seu parceiro de farda, ora testemunha, em patrulhamento de rotina quando foi irradiada a informação de que 2 (dois)homens teriam sido flagrados furtando cabos telefônicos e outros fios no interior da propriedade situada no local dos fatos. Que a denúncia partiu do Sr. Wilson Gonçalves de Camargo, proprietário do imóvel, que, em razão de sua idade avançada, não pôde se fazer presente neste plantão policial. Que, lá estando, após confirmarem a veracidade da informação, lograram deter ambos os suspeitos, posteriormente identificados como os ora indiciados, ainda no interior do imóvel. Que, quando da chegada da guarnição, DANIEL ainda se encontrava no alto da torre de transmissão, realizando a subtração dos fios da empresa VIVO. Que, realizada a competente vistoria, foram localizados vários rolos de fios, de qualidade e modelos diversos, todos pertencentes à empresa vítima, já separados para posterior remoção. Que também foram localizadas, a partir de indicações dos indiciados, uma pequena faca e um alicate, utilizados para cortar os fios. Que, indagados, os implicados nada esclareceram. Que, segundo apurado, aparentemente os implicados ingressaram no imóvel após romper o alambrado que o guarnece". Em juízo confirmou os fatos. Acrescentou que o solicitante era o proprietário do imóvel, onde havia torre de telefonia de celular. Assim, de rigor a condenação dos réus. De fato, Daniel confessou a prática delitiva e delatou seu comparsa. Ademais, eles foram surpreendidos pelos GCM no imóvel tentando subtrair fios. Destarte, inequívoca autoria. Outrossim, considerando que o crime foi praticado concurso de pessoas e rompimento de obstáculos, conforme laudo pericial a fls. 179/184 e 185/186 e a prova oral coligida nos autos, deverão incidir as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do § 4º, do art. 155, do CP. Diante do acima exposto, requer o Ministério Público a condenação dos réus nos termos acima propostos. Na aplicação da pena há que se observar que o réu Daniel é duplamente reincidente (certidões a fls. 101/104) e Elias não ostenta antecedentes (certidões a fls. 108/109), observando apenas que foi preso recentemente por outros fatos (fls. 143)".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, os acusados foram denunciados e estão sendo processados como incursos no art. 155, §§ 4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma como descrito na inicial. Encerrada a

instrução probatória, verifica-se, em primeiro lugar, que deve ser reconhecida a ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Excelência, conforme se observa dos autos, a conduta narrada na denúncia não apresenta suficiente ofensividade a justificar a intervenção penal, devendo ser aplicado o princípio da insignificância. Com efeito, o princípio da insignificância incide sobre todo e qualquer caso em que se tem como objeto uma conduta de pequeno potencial ofensivo e danoso, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Trata-se de valor jurídico atribuído às condutas que, se colocadas para análise do Poder Judiciário, somente atrasariam ainda mais as soluções das controvérsias que, de fato, necessitariam do exame do Magistrado, em contrapartida àquelas condutas que não afetam profundamente a paz social. Não se trata, obviamente, de banalizar a importância da intervenção penal, mas de buscar a justa compensação para a sociedade no que diz respeito ao dano que o acusado possa ter causado a ela. Portanto, parece mais adequado que o réu responda por um ilícito civil ou administrativo do que por um penal. A suposta conduta dos acusados não pode ser considerada como ataque intolerável ao bem jurídico tutelado e não deve ser entendida como algo que tenha efetivamente perturbado o convívio social, pois configura a insignificância propriamente dita ou absoluta: o fato, por ser ínfimo, não chega a expressar valoração digna de tutela da norma penal. Não ocorreu qualquer afetação concreta ao bem jurídico patrimônio. Ao revés, teria ocorrido a tentativa de subtração de fios de cobre, que sequer foram avaliados pela Autoridade Policial. Dessa forma, resta evidente que a conduta não foi apta a produzir resultado jurídico relevante, sendo, pois, materialmente atípico o fato, o que conduz à necessária absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, III, do CPP. Todavia, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, verifica-se, ainda assim, a necessidade de ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS. Com efeito, não há a presença de um conjunto probatório robusto que autorize a prolação de uma sentença condenatória. Nesta data, a testemunha Domiciano, Guarda Municipal, declarou que receberam uma denúncia na central formulada por um vizinho da empresa de telefonia, a qual informava que dois indivíduos estariam furtando cabos da torre de celular. Foram ao local e encontraram os réus. Perceberam que parte do alambrado estava violado. Um dos indivíduos estava em cima da torre, enquanto o outro estava no solo. Eles disseram informalmente que furtaram os fios e iriam vender em um ferro-velho da cidade. Perguntaram como os cabos foram retirados e o réu Daniel indicou o local onde estava um alicate e uma faca, que teriam sido dispensadas pelos acusados. Não conhecia os réus antes dos fatos. O réu Daniel, em interrogatório, declarou que quem estava em cima da torre era o Elias. Estava apenas vigiando o local. Estava passando pela torre quando o Elias lhe chamou e disse que iria subtrair os fios, oferecendo, ainda, dinheiro ao réu para que ele permanecesse “de vigia”. Quando ele estava subtraindo os fios, os Guardas chegaram. Porém, iriam subtrair os fios para vender. Quando chegou no imóvel, já existia um buraco e viu o Elias passando pelo local. O Elias já lhe disse que teria subtraído fios de lá em outras ocasiões. Está arrependido. Já o réu Elias, por sua vez, não compareceu à audiência designada para sua oitiva, todavia, sua ausência não pode ser tomada em seu prejuízo, haja vista que está inserida na autodefesa do acusado a opção por deixar de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, à semelhança do direito constitucional ao silêncio. Todavia, em que pese o acusado Daniel ter reconhecido, ainda que de forma parcial, a prática dos fatos, sua confissão, como qualquer outra prova, possui valor relativo e deve ser corroborada pelo restante dos elementos dos autos, o que não ocorreu neste caso. Isso porque, em relação aos Guardas Municipais, seus depoimentos invariavelmente são exarados sem a isenção que deles se espera. Suas assertivas no processo, dada a evidente parcialidade que as permeia, não exercem sua função precípua, qual seja: a de explicitarem uma fotografia neutra da realidade não presenciada pelo Magistrado. Neste ponto, cabe ressaltar que a Defensoria Pública também não afirma que o GCM mentiu em juízo, apenas que reproduziu a sua percepção dos fatos, naturalmente influenciada por sua condição de órgão da segurança patrimonial do Município. Assim sendo, percebe-se que não há substrato probatório mínimo que comprove a autoria delitiva, pelo que o réu deve ser ABSOLVIDO, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Caso Vossa Excelência se posicione pela manutenção da condenação, pugna a Defensoria Pública, então, pelo AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. Isso porque, quanto ao repouso noturno, causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do art. 155 do Código Penal, tem-se que a intenção do legislador em inseri-la no contexto do crime patrimonial de furto foi atribuir maior proteção jurídica à esfera de descanso do titular (fático ou jurídico) do patrimônio objeto do crime. O reduto de descanso das pessoas, naturalmente, é a residência, cuja proteção jurídica advém desde a Constituição Federal, especialmente no que toca ao disposto no art. 5º, inciso XI, no sentido de que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Ocorre que a conduta versada nos autos, com a máxima vênia, não guarda pertinência com a incidência da referida causa de aumento de pena, sobretudo porque os fatos, supostamente, não teriam ocorrido em uma residência. Ademais, é entendimento pacífico que a causa de aumento em questão NÃO se aplica à modalidade qualificada do furto, pela topografia legal. Inclusive, em relação às inúmeras divergências a respeito do assunto, cumpre observar que, recentemente, a 3ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o sistema de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), afastou a aplicabilidade da referida causa de aumento ao furto qualificado, sendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.039, determina que a referida decisão possui caráter vinculante e deve ser observada pelas E. Instâncias Inferiores. Dessa forma, a causa de aumento em questão merece ser afastada. Ademais, no caso, também deve ocorrer o AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Isso porque, a despeito da perícia realizada no imóvel, não é possível atribuir, com certeza, a autoria do concurso de obstáculo aos réus, eis que o laudo técnico, por si só, não permite esta conclusão. Pugna-se, também, pelo AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. Isso porque, após regular instrução probatória, restou evidenciado que não houve a necessária comprovação do liame subjetivo entre os acusados para a prática do furto em questão. Assim, contrariamente ao pretendido pela acusação, não basta, apenas, que se diga que os agentes estavam no local dos fatos à época da ocorrência do delito, sendo necessária a demonstração de que ambos os agentes estavam subjetivamente conectados à empreitada criminosa. Postula-se, ainda, em relação ao acusado Elias, pelo RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. Isso porque se encontram presentes todos os requisitos do artigo 155, § 2º, do CP. Com efeito, como se observa da folha de antecedentes, o acusado Elias é tecnicamente primário e deve ser considerado que a res furtiva apresenta pequeno valor, eis que sequer avaliada pela autoridade policial. Urge ressaltar, ainda, que, consoante entendimento jurisprudencial dominante, presentes os requisitos legais, é direito subjetivo da acusada que seja aplicado o privilégio. Postula-se, ainda, pela redução da pena pela tentativa no patamar máximo previsto em lei. Isso porque os acusados foram abordados enquanto ainda estavam no interior do estabelecimento, sendo que o bem que seria subtraído sequer foi movimentado para outro local. Portanto, fica evidente a brevidade do iter criminis por eles percorrido, devendo haver a redução da pena no máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). Requer-se, também, em relação ao acusado Daniel, o RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. Excelência, diante das declarações colhidas em audiência, no sentido de que o réu Daniel apenas ficou vigiando o local enquanto o outro acusado efetivamente subtraía os objetos, deve-se reconhecer a participação de menor importância, nos termos do art. 29 do CP. Com efeito, preconiza o artigo 29 do Código Penal, ao tratar do concurso de agentes, que as penas serão aplicadas na medida da sua culpabilidade, devendo haver redução para aquele que participa de forma menos relevante: “Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”. Portanto, sendo considerado mero partícipe, sem ter perpetrado a própria subtração, de rigor reconhecer a hipótese de diminuição em testilha, com a aplicação do redutor no patamar máximo, adequado à relevância de sua ação no caso

concreto. Por fim, requer seja reconhecida a NECESSIDADE DE SE AFASTAR O PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS (MATERIAIS E MORAIS). Na hipótese de Vossa Excelência

entender pela condenação do réu, verifica-se que o Ministério Público postula, como efeito da procedência da ação, a fixação do dever de pagamento de valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima. É certo que a vítima pode, se desejar, buscar a reparação dos danos causados pela prática da infração. Todavia, tratando-se de questão patrimonial (e até disponível), o ideal é que ela o faça em âmbito próprio (ou seja, mediante um processo civil), oportunizando ao demandado a produção de provas específicas a respeito do assunto, inclusive com eventual discussão a respeito do valor devido a título de indenização. Ainda que isso tudo não bastasse, não se tem nos autos demonstração efetiva e inequívoca de dúvidas a respeito dos prejuízos sofridos pela empresa-vítima, sendo que o valor foi definido por meio de poucos documentos apresentados durante o inquérito policial, dificultando, inclusive, o exercício do contraditório e consequente produção de contraprova sobre a questão. Nesse sentido, são interativos os julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. I. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando a ré a possibilidade de se defender e produzir contraprova. III. Agravo regimental a que se nega provimento. ..EMEN: (AGRESP 201402517776, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:29/02/2016 ..DTPB:.). No mesmo sentido, a doutrina pátria entende que o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal poderá ser aplicado desde que sejam garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Confirma-se: "Mas, é no fato de que em não havendo previsão expressa de pedido sem que haja, portanto, a exposição de fatos referentes à indenização de forma particular e individualizada de modo que possa gerar o cabível contraditório sobre o tema que parece residir os maiores entraves para que se admita a plena compatibilidade do presente artigo com a estrutura constitucional." (CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de Processo Penal: Comentários Consolidados e Crítica Jurisprudencial, 4ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 584). E, ainda que, no caso concreto, fosse possível admitir, em tese, a fixação da reparação do dano no âmbito da sentença penal, para estipulação ao seu valor, deve-se levar em conta as funções ressarcitória e punitiva. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela sofreu. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita o seu comportamento. Ora, tais provas não são objeto e nem factíveis de produção no âmbito do Processo Penal, no qual a situação financeira das partes sequer é objeto de análise. Os Tribunais pátrios têm se posicionado no sentido de que é necessário tomar cuidado para não se ter o enriquecimento ilícito em ações penais com esse tipo de pedido. Ademais, frisa-se, não é no Juízo criminal que se afigura a questão da lesão patrimonial supostamente sofrida pela vítima, pois não é este o objeto principal que se discute nos autos e, diante dos limites da instrução criminal, podem escapar discussões de suma importância para se auferir, com o acerto mais justo, qual o valor a ser fixado para se reparar o dano sofrido. Por fim, ainda que não sejam acolhidos os argumentos acima, o valor estabelecido é inviável às condições econômicas dos acusados, parte assistida pela Defensoria Pública e claramente hipossuficiente, que não têm qualquer condição de arcarem com o montante sem prejuízo do próprio sustento. Dessa forma, deve ser reconhecida a vulneração ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, afastando-se a obrigação de reparação dos danos ou, então, reduzindo-se o valor fixado para um montante compatível com a capacidade econômico-financeira dos acusados. No tocante

a eventual dosimetria da pena, a Defensoria Pública pugna pela: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a culpabilidade dos acusados não extrapola aquela inerente ao tipo penal, sendo que a vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase; 2) o reconhecimento, em relação ao acusado Daniel, da atenuante da confissão espontânea (ainda que parcial), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; 3) a fixação do regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c" e § 3º, do CP, bem como diante da Súmula n. 269 do C. STJ e do disposto no artigo 387, § 2º, do CPP; 4) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, haja vista que está presente a circunstância do artigo 44 do Código Penal, observando-se, ainda, que o acusado Daniel não é reincidente específico em crime de furto; e 5) seja assegurada a possibilidade dos acusados aguardarem o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que justifique a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP)".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

DANIEL SILVESTRE PIRES e ELIAS MICAEL GREGÓRIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de junho de 2022, por volta de 21h50min, na Rua Dona Rosália, nº 330, Bairro Pauliceia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, agindo em concurso, caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios, e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si, 4,4kg de fios e cabos, instalados em torre de telefonia e pertencentes à empresa Vivo – Telefônica Brasil S. A.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, durante o repouso noturno, os acusados romperam parte do alambrado que guarnece o imóvel em que está fixada uma torre de telefonia da empresa Vivo e cortaram e separam fios e cabos de telefonia que estavam ali instalados. Guardas municipais foram acionados e flagraram DANIEL e ELIAS no interior do imóvel, na posse de vários rolos de fios e cabos já cortados e separados para remoção, além de uma faca e um alicate. No momento da chegada dos policiais, DANIEL ainda se encontrava no alto da torre de transmissão, realizando o corte e subtração de mais cabos da empresa de telefonia.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para fazer constar a data correta dos fatos. Recebida a denúncia e seu aditamento em 29.06.2022 (fls. 116/117), os réus foram citados (fls. 148 e fls. 152) e apresentaram defesa preliminar (fls. 157/158), seguindo-se a decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 159/161).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha. Após, o corréu DANIEL foi interrogado, prejudicado o interrogatório do corréu ELIAS, que se tornou revel.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal dos réus.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelas fotografias de fls. 16/17 e pelos laudos periciais de fls. 179/184 e 185/186.

A autoria também restou comprovada.

Na fase policial, os acusados valeram-se do direito de permanecer em silêncio (fls. 05/06 e fls. 07/08).

Em juízo, DANIEL confessou a prática do crime. Disse que estava bebendo, passou na frente do imóvel e viu Elias, que o chamou para ficar de vigia para pegar fios e dividir. Asseverou que aceitou, Elias entrou e subiu na torre. Logo depois, chegaram várias viaturas. Alegou que, quando chegou no local, já havia um buraco no alambrado e, depois, Elias falou que já tinha praticado furtos várias vezes no local.

ELIAS, a seu turno, tornou-se revel.

O guarda municipal Domiciano relatou que receberam solicitação da Central dando

conta de que ao lado do imóvel do solicitante, num terreno onde há torre de celular operadora Vivo, havia dois homens furtando cabos. Atestou que chegaram rapidamente, porque estavam próximos do local, e avistaram um pedaço da cerca rompido, um indivíduo no solo e outro no alto da torre, salvo engano o Daniel. Atestou que eles foram retirados do imóvel e confirmaram que estavam no local para furtar cabos para vender em ferro velho da cidade. Aduziu que os questionaram como eles estavam retirando o cabo e Daniel lhes mostrou local onde tinha dispensado faca e alicate de corte.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Emerson, ouvido a fls. 04.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: “Habeas Corpus – Tráfico de drogas– Pleito de revogação da prisão preventiva – Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade – Artigo 301 do CPP – Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante – Crime de Tráfico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Jurisprudência do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. No mais, eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente.

Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não bastasse essa orientação já consolidada na jurisprudência, há que se ressaltar que, conquanto não seja essa essencialmente sua função, o guarda municipal está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º,

inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

O recente entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prisão em flagrante perpetrada por guardas municipais é nula sempre que desenvolverem ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo e atividade investigativa, por violação de suas atribuições constitucionais, não é aplicável nos casos, como o dos autos, em que os guardas municipais deparam-se com situação de flagrante que não envolve as atribuições próprias das Polícias Civil e Militar.

Nesse contexto, de rigor a condenação: os acusados foram flagrados pelos guardas municipais em plena prática delitiva, na posse de vários rolos de fios e cabos já cortados e separados para remoção, além de uma faca e um alicate utilizados na prática do delito (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15 e laudo pericial de fls. 185/186).

E nem se alegue a insignificância da conduta, para sustentar sua atipicidade.

A legislação penal brasileira não consagra o “princípio da insignificância” ou o da “bagatela”.

A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuassem na prática de subtrações, desde que laborassem com inteligência, ou seja, escolhessem sempre bens de pequeno valor (cf. Apelação nº 0012073-05.2010.8.26.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Maria Tereza do Amaral, j. 20.06.12).

O pequeno valor da res furtiva não importa na incidência do denominado princípio da insignificância.

Aliás, para a aplicação do princípio da insignificância, de suma relevância é perquirir se a conduta constitui fato isolado na vida do acusado ou se integra a prática habitual de ilícitos contra o patrimônio alheio, de modo a fazer da criminalidade seu meio de vida e próprio sustento. Verificada a primeira hipótese, a exclusão da tipicidade material é medida de rigor. Todavia, se renitente, contumaz, torna a conduta não um irrelevante penal, mas um fato socialmente relevante, outro ilícito penal que se acrescenta na sua vida pregressa de lesão ao patrimônio alheio (cf. APELAÇÃO CRIMINAL nº 0062335-56.2010.8.26.0050, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 25.09.12).

O corréu DANIEL é reincidente, de modo que, por qualquer ângulo que se observe a questão, descaberia, com relação a ele, a incidência do invocado princípio da insignificância.

E ficaram suficientemente caracterizadas as qualificadoras previstas no art. 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, eis que o delito foi praticado por dois agentes, que ingressaram no local mediante rompimento da grade do alambrado que circundava o imóvel, conforme atestado no laudo pericial de fls. 179/184 e corroborado pela prova oral produzida.

Consigno que, ainda que o corréu Daniel não tenha diretamente rompido o alambrado do imóvel, como alega, aderiu, de qualquer modo, à conduta do corréu Elias, respondendo, portanto, pela qualificadora de ordem objetiva.

O furto ocorreu às 21h50min. Porém, o C. Superior Tribunal de Justiça, fixou, em decisão datada de 25.5.2022, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”. (REsp 1.888.756; REsp 1.890.981 e REsp 1.891.007).

Por fim, consigno que não cabe o reconhecimento do furto privilegiado com relação ao corréu Daniel, reincidente.

No que tange ao corréu Elias, primário, faz-se necessário o reconhecimento do furto privilegiado, como pleiteado pela combativa Defesa, uma vez que estão presentes os requisitos previstos no artigo 155, § 2.º, do Código Penal. Isso porque, não obstante a ausência de avaliação, não há como afirmar que a res (4,4kg de fios e cabos) possui valor superior ao salário mínimo vigente na data dos fatos.

Anoto que o fato de se tratar de furto qualificado não impede o reconhecimento do privilégio, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ, consubstanciada na Súmula

n. 511: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva"

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que a presença de mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a presença de somente uma já seria suficiente para caracterizar o furto qualificado.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o tipo penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)" (Grifos nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça: "Apelação Furto duplamente qualificado Autoria e materialidade bem comprovadas Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas Condenação que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente demonstradas pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância judicial impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos Réu reincidente Personalidade negativa evidente Penas e regime mantidos, Recurso desprovido." (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca: Taquaritinga; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).

De outro lado, DANIEL é reincidente. Entretanto, essa circunstância só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem.

Assim, fixo a pena-base em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo legal, para ambos os acusados.

Na segunda fase de fixação de pena, com relação à DANIEL, está presente a agravante da reincidência (autos nº 0006837-57.2015 da 1ª Vara Criminal local e nº 0017340-06.2016 desta 4ª Vara Criminal - cf. cert. 101/104). De outro lado, confessou a prática do crime, razão pelo qual, sopesando as circunstâncias agravante e atenuante, aplico o aumento de um sexto, resultando dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa. Quanto à ELIAS, não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Inexistem causa de aumento. Por outro lado, aplico, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, a redução de metade, totalizando um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e seis dias-multa para o corréu DANIEL e um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa para o corréu ELIAS.

Em tema de tentativa, é de ser levado em conta, para efeito da fração a ser considerada na redução da pena, o iter criminis percorrido pelo agente (cf. JUTACRIM 87/222). Assim, sendo os acusados detidos ainda no interior do imóvel, logo após terem se apoderado da res, de rigor a redução intermediária. "Em casos de tentativa que não chega a haver subtração, a diminuição, pela incipiência da ação desencadeada, deve ser de 2/3; se ocorre o apossamento da res pelo furão, sem que este chegue a se afastar do local, a redução aplicável é a de metade da pena-base; e, se a subtração ocorre, o larápio logrando afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranquila do material, o decréscimo observável será o de 1/3, até porque, se alcançada a posse imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de furto consumado".

Com relação a ELIAS, em razão do reconhecimento do privilégio, substituto a pena de reclusão pela de detenção, anotando que não é adequada redução da pena ou fixação

somente de multa, por se tratar de furto biqualeficado.

Em razão da reincidência, o réu DANIEL não faz jus à substituição prevista no art. 44 do Código Penal, nem a concessão de "sursis".

Não obstante a reincidência, considerando o tempo de prisão cautelar e o disposto pela súmula nº 269 do STJ, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.). Quanto a ELIAS, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, observadas as disposições do art. 46 do Código Penal, em local a ser designado na fase de execução (LEP, art. 149, I), e multa de mais dez diárias, no valor mínimo legal.

Na hipótese de ser convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o cumprimento se dará no regime aberto (CP, art. 33).

Por fim, não pode ser determinada a reparação de danos requerida pelo Assistente da Acusação em alegações finais, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo a parte interessada se valer dos meios ordinários para esse fim.

A respeito do procedimento para a fixação da indenização civil, a lição de Guilherme de Souza Nucci: "admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa" (Código de Processo Penal Comentado, 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 701)".

No caso em tela, as provas produzidas nos autos foram suficientes para se reputar demonstrada a ocorrência de danos, mas não de seu valor específico, que, aliás, foi meramente estimado na denúncia.

3. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar DANIEL SILVESTRE PIRES, qualificado nos autos, à pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e seis dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado regime inicial semiaberto e vedado o direito de apelar em liberdade, como incurso no art. 155, §4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e ELIAS MICAEL GREGÓRIO, qualificado nos autos, à pena de um ano e dois meses de detenção e seis dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, observadas as disposições do art. 46 do Código Penal, em local a ser designado na fase de execução (LEP, art. 149, I), e multa de mais dez

diárias, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155, §2º e 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Recomende-se o corréu DANIEL no estabelecimento em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Custas na forma da Lei 11.608/03.
Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.
Pelo CORRÉU DANIEL SILVESTRE PIRES foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida em relação ao corréu DANIEL SILVESTRE PIRES.
Ainda pelo DEFENSOR foi dito que aguarda a intimação do corréu ELIAS MICAEL GREGORIO acerca da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data em relação ao corréu DANIEL SILVESTRE PIRES.

2) Com relação ao corréu DANIEL SILVESTRE PIRES, cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD, SARC e TRE.

3) Com relação ao corréu DANIEL SILVESTRE PIRES, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

4) Com relação ao corréu DANIEL SILVESTRE PIRES, tratando-se de multa cumulativamente aplicada, providencie-se inserção do valor atualizado no sistema informatizado, consignando-se o montante de R\$243,38, equivalente a 7,61 UFESPs, oportunamente abrindo-se vista ao Ministério Público para as providências cabíveis.

5) O corréu DANIEL SILVESTRE PIRES, foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.

6) Com relação ao corréu DANIEL SILVESTRE PIRES, regularizados os autos, archive-se com a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", nos termos do Art. 480, §1º, das NSCGJ.

7) Intime-se o corréu ELIAS MICAEL GREGORIO acerca da sentença proferida.
Após, tornem conclusos para deliberações.
Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]